

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4345/2536

นาง อุไร ทิมมาศย์

บริษัท โรแยลครีฟ บีช โฮเต็ล จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1349, มาตรา 1390, มาตรา 1391, มาตรา 1392, มาตรา 1401

ป.วิ.พ. มาตรา 142

โจทก์และคนในครอบครัวโจทก์ใช้ทางในที่ดินของจำเลย ออกสู่ทางสาธารณะมากกว่า 10 ปีแล้ว แต่ก่อนปี 2498 ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวล้วนแต่อยู่ในตระกูล ของ โจทก์ทั้งสิ้น การใช้ทางในระยะเวลาดังกล่าวจึงเป็นการ ขออาศัยกันระหว่างหมู่ญาติหรือโดยถือวิสาสะ จึงไม่อาจได้ ภารจำยอม แต่นับตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2498 ที่ ส. ขายที่ดินดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกไปและมีการโอนกันต่อๆมาจนถึงจำเลยซึ่งรับโอนเมื่อปี 2526 เป็นเวลาเกินกว่า 10 ปี การใช้ทางของโจทก์และคนในครอบครัวเป็นไปโดยสงบและเปิดเผย มิได้ขออนุญาตจากผู้ใด จึงตกเป็นภารจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์โดยอายุความ ที่ดินของโจทก์ทางด้านทิศตะวันออกติดแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าบ้านโจทก์มีทำน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นทางสาธารณะที่โจทก์สามารถใช้สัญจรไปมาได้อยู่แล้ว แม้ในปัจจุบันจะไม่ค่อยมีผู้ใช้สัญจรไปมาก็ยังถือไม่ได้ว่าที่ดินของโจทก์ถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะได้ ทางในที่ดินของจำเลยที่โจทก์ใช้เดินออกสู่ถนนพระรามที่ 3 อยู่จึงไม่เป็นทางจำเป็น โจทก์ฟ้องขอให้เปิดทางภารจำยอมกว้าง 3.50 เมตรจำเลยให้การว่า โจทก์และคนในครอบครัวโจทก์ไม่เคยใช้ ทางบนที่ดินของจำเลยออกสู่ทางสาธารณะ จึงไม่มีทางภารจำยอมคำให้การดังกล่าวย่อมมีความหมายไปถึงว่า ไม่มี

ทางการจำยอมแม้แต่เมตรเดียวด้วยการที่ศาลวินิจฉัยไปถึงความกว้างของทางการ
จำยอมว่ามีความกว้าง 1 เมตร จึงอยู่ในขอบเขตของคำให้การ ไม่เป็นเรื่องนอกฟ้อง
นอกประเด็น ทางพิพาทอยู่ห่างจากแนวเขตที่ดินของจำเลยทางด้านทิศใต้เข้ามา
2.30 เมตร โจทก์ใช้ทางพิพาทไม่สะดวก ทั้งการสร้างรั้วหรืออาคารในที่ดินของ
จำเลยโดยเว้นทางพิพาทไว้ยอมทำให้จำเลยเสียที่ดินด้านสุดแนวเขตที่ดินทางด้าน
ทิศใต้เว้นแต่จะกั้นรั้วหรือสร้างอาคารเป็นสองตอนซึ่งเป็นการเพิ่มภาระแก่จำเลยและ
ใช้ประโยชน์จากที่ดินทางด้านทิศใต้สุดแนวเขตที่ดินไม่ได้เท่าที่ควร แต่หากได้ย้าย
ทางไปอยู่ตรงสุดแนวเขตที่ดินของจำเลยทางด้านทิศใต้แล้วย่อมไม่ทำให้ความ
สะดวกในการใช้ทางเดินของโจทก์ต้องลดน้อยลงกลับจะทำให้โจทก์เดินระยะทางสั้น
เข้าเพราะไม่ต้องเดินวกไป ทางขวามากดังที่เป็นอยู่เดิม และการย้ายการจำยอมเป็น
ประโยชน์แก่จำเลยด้วย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1392 การที่
ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ย้ายการจำยอมไปสุดแนวเขตที่ดินของจำเลยทางด้านทิศใต้จึง
ไม่เป็นการนอกฟ้องนอกประเด็น การจดทะเบียนการจำยอมนั้นพึงต้องถือว่าเป็นการ
อันจำเป็นเพื่อรักษาและใช้การจำยอมประการหนึ่ง ตามนัยแห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1391 แม้โจทก์จะได้มาซึ่งการจำยอมโดยอายุความ โจทก์
ซึ่งเป็นเจ้าของสามยทรัพย์ก็ชอบที่จะเรียกให้จำเลยเจ้าของภารยทรัพย์จดทะเบียน
ทางการจำยอมแก่ตนได้ โจทก์สร้างสะพานไม่ใช้เดินเข้าออกบนทางการจำยอม
เนื่องจากน้ำท่วม บางครั้งต้องเดินลุยน้ำแต่หากท่วมมากก็ต้องถอดกางเกงแล้วเดิน
ออกไป ดังนั้นที่จำเลยถมดินทำให้ทางการจำยอมสูงกว่าระดับที่ดินของโจทก์ก็ยิ่ง
ทำให้โจทก์ ได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้นไม่ต้องเดินสะพานไม้อีกต่อไปการถมดินของ
จำเลยจึงมิได้ทำให้ประโยชน์แห่งการจำยอมลดไป หรือเสื่อมความสะดวกยอมทำได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 5537 ตำบลช่อง
นนทรี อำเภอพระโขนง (ยานนาวา) กรุงเทพมหานคร จำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
ที่ดินโฉนดเลขที่ 5484 ที่ดินทั้ง 2 แปลงอยู่ติดกันโดยที่ดินของจำเลยอยู่ด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของที่ดินโจทก์ โจทก์ได้เข้าอาศัยในที่ดินของโจทก์ตั้งแต่ปี
2491 โดยโจทก์และครอบครัวรวมทั้งบุคคลอื่นซึ่งพักอาศัยในบ้านทั้ง 4 หลัง ในที่ดิน
ของโจทก์ได้ใช้คันสวนบนที่ดินของจำเลยเป็นทางผ่านออกสู่ทางสาธารณะเพื่อไปยัง
วัดคลองใหม่และออกสู่ถนนนางลิ้นจี่หรือถนนสาธุประดิษฐ์มาโดยตลอด และในปี
2517 ภายหลังที่ทางราชการได้ตัดถนนพระรามที่ 3 เลียบแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านที่ดิน
ของจำเลย โจทก์ได้ใช้คันสวนเดิมในที่ดินของจำเลยเป็นทางเข้าออกสู่ถนนพระราม
ที่ 3 ตลอดมาจนปัจจุบันโดยสงบและเปิดเผยรวมระยะเวลาที่ใช้ทางดังกล่าวไม่น้อย
กว่า 60 ปี คันสวนบนที่ดินของจำเลยขนาดกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางประมาณ 34
เมตร จึงตกเป็นทางภาระจำยอมแก่ที่ดินโจทก์นอกจากนี้ที่ดินของโจทก์อยู่ในที่ปิด
ล้อมโดยทิศเหนือและทิศตะวันตกติดที่ดินของจำเลย ทิศใต้ติดที่ดินของผู้อื่น ส่วน
ทิศตะวันออกติดแม่น้ำเจ้าพระยาหลังจากถนนพระรามที่ 3 ได้ตัดผ่านที่ดินบริเวณ
ใกล้เคียงแล้วโจทก์และประชาชนจึงเลิกใช้เส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นทางสาธารณะ
และใช้เส้นทางผ่านคันสวนที่ดินของจำเลยออกสู่ถนนพระรามที่ 3 คันสวนบนที่ดิน
ของจำเลยดังกล่าวจึงเป็นทางจำเป็นสำหรับที่ดินของโจทก์ด้วย ต่อมาในเดือน
กุมภาพันธ์ 2531 เป็นต้นมาจำเลยได้สร้างเขื่อนเป็นกำแพงและถมที่ดินของจำเลย
สร้างกำแพงรั้วคอนกรีตด้านที่ติดกับถนนพระรามที่ 3 โดยเจตนาปิดกั้นไม่ให้โจทก์
ใช้คันสวนเป็นเส้นทางผ่านเข้าออกสู่ถนนพระรามที่ 3 ได้ตามปกติ ขอให้บังคับ
จำเลยรื้อกำแพงคอนกรีตที่สร้างขึ้นปิดกั้นคันสวนทั้งทางด้านที่ติดกับที่ดินของโจทก์
และที่ติดกับถนนพระรามที่ 3 บนทางพิพาทออกกว้าง 3.50 เมตรและเปิดเป็นทาง
ยาวตลอดแนวจากทางด้านทิศตะวันออกไปยังด้านทิศตะวันตกจนสุดที่ดินของจำเลย
ถึงด้านที่ติดกับถนนพระรามที่ 3 โดยให้จำเลยทำสภาพที่ดินให้เหมือนเดิม และให้

จำเลยไปจดทะเบียนการจำยอมทางพิพาทแก่โจทก์ หากไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า เดิมที่ดินโฉนดเลขที่ 5537 และที่ดินโฉนดเลขที่ 5484 เป็นที่ดินแปลงเดียวกัน ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์รวมของนายขำ นางบาง นายสำลี นายสำฤทธิ์ นางสาวสำรัต และนายสำรวยซึ่งเป็นญาติกับโจทก์และสามี การใช้ทางดังกล่าวก็โดยอาศัยหรือโดยวิสาสะเพราะความเป็นญาติสนิทคุ้นเคยกัน คັນสวนดังกล่าวของจำเลยจึงไม่อาจตกเป็นทางภาระจำยอมได้ ทั้งโจทก์และครอบครัวรวมทั้งบุคคลที่อยู่ในที่ดินโฉนดเลขที่ 5537 ก็หาได้ใช้คັນสวนบนที่ดินของจำเลยเป็นทางผ่านออกสู่ทางสาธารณะไม่ เนื่องจากแนวคັນสวนและสะพานไม้ที่โจทก์และบุคคลดังกล่าวใช้เดินแต่เดิมนั้นตัดเป็นแนวตรงออกมาทางด้านทิศตะวันตกกผ่านที่ของผู้อื่นมิใช่ที่ดินของจำเลยและขณะที่จำเลยซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 5484 นั้น ไม่มีคັນสวนหรือสะพานไม้ในที่ดินดังกล่าว โจทก์เพิ่งสร้างสะพานไม้ใช้เดินผ่านในที่ดินของจำเลยภายหลังที่จำเลยรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวมา นับถึงปัจจุบันยังไม่ถึง 10 ปีทางเดินบนที่ดินของจำเลยจึงไม่เป็นทางภาระจำยอม นอกจากนี้ที่ดินของโจทก์มิได้อยู่ในที่ปิดล้อม เพราะโจทก์และสามีเคยเดินผ่านที่ดินของผู้อื่นเพื่อออกสู่ถนนสาธารณะและเป็นการสะดวกกว่าที่โจทก์จะเดินผ่านที่ดินของจำเลย ทั้งที่ดินของโจทก์ด้านทิศตะวันออกติดแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งสะดวกและรวดเร็วในการสัญจรมากกว่าจะเดินผ่านที่ดินของจำเลย ทางเดินบนที่ดินของจำเลยจึงมิใช่ทางจำเป็น และในขณะที่จำเลยซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 5484 นั้นผู้ขายได้รับรองกับจำเลยแล้วว่าที่ดินดังกล่าวไม่ตกอยู่ในภาระจำยอมหรือถูกรอนสิทธิแต่อย่างใดการที่จำเลยสร้างเขื่อนเป็นกำแพงและถมดินในที่ดินของจำเลย จึงไม่เป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 5484 ตำบลช่องนนทรีอำเภอยานนาวา (พระโขนง) กรุงเทพมหานคร ด้านสุดแนวเขตที่ดินทางด้านทิศใต้กว้าง 1 เมตร ยาว

ตลอดแนวเขตที่ดินจากด้านทิศตะวันออกไปจนสุดยังทิศตะวันตกเป็นการจำยอมแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 5537 ตำบลช่องนนทรี อำเภอยานนาวา (พระโขนง) กรุงเทพมหานครของโจทก์ ให้จำเลยรื้อรั้วกำแพงคอนกรีตที่ปิดกั้นเปิดเป็นทางและไปจดทะเบียบนทางการจำยอมแก่โจทก์ หากไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ที่ดินโฉนดเลขที่ 5484 ตำบลช่องนนทรี อำเภอยานนาวา (พระโขนง) กรุงเทพมหานครทางด้านทิศใต้กว้าง 1 เมตร ยาวตลอดแนวเขตที่ดินจากด้านทิศตะวันออกไปสุดยังทิศตะวันตก ห่างจากแนวเขตที่ดินของจำเลยด้านทิศใต้ 2.30 เมตร เป็นการจำยอมแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 5537 ตำบลช่องนนทรี อำเภอยานนาวา (พระโขนง) กรุงเทพมหานคร ของโจทก์ ให้จำเลยรื้อรั้วกำแพงคอนกรีตที่ปิดกั้นเปิดเป็นทาง คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 5537 และเลขที่ 5484 ตำบลช่องนนทรี อำเภอยานนาวา (พระโขนง) กรุงเทพมหานคร เดิมเป็นที่ดินแปลงเดียวกัน ต่อมาได้แบ่งแยกออกเป็นสองแปลงโดยแปลงโฉนดเลขที่ 5484 อยู่ติดถนนพระรามที่ 3 ได้มีการโอนขายต่อกันมาจนกระทั่งจำเลยเป็นผู้รับโอนคนสุดท้ายเมื่อปี 2526 ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อแรกมีว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 5537 ตำบลช่องนนทรี อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานครหรือไม่ ในปัญหานี้ ได้ความจากคำเบิกความของโจทก์ และนายยินดีสามีโจทก์ประกอบกับสารบาญแก้ทะเบียบนของโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข 3 ว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 5537 เดิมเป็นกรรมสิทธิ์รวมของนายขำ นางบางนายสำลี

นายสำฤทธิ์ นางสาวสำริด และนายสำรวย ภายหลังได้มีการแบ่งมรดกที่ดินดังกล่าว ตกให้แก่นางน้อมมารดาของนายยินดีในปี 2517 นางน้อมยกที่ดินดังกล่าวให้แก่ นายยินดีและโจทก์ต่อมานายยินดียกส่วนของตนให้แก่โจทก์ทั้งหมด โจทก์จึงมีชื่อในทะเบียนเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งแปลงแต่เพียงผู้เดียว แม้จำเลยจะฎีกาว่า โจทก์ เบิกความขัดแย้งกันในตัวโดยตอบทนายโจทก์ซักถามว่า นางน้อมยกที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่โจทก์และนายยินดีแต่ตอบทนายจำเลยถามค้านว่าโจทก์ได้ซื้อจากนางน้อมแล้วใส่ชื่อโจทก์และนายยินดีเป็นเจ้าของร่วมน่าจะฟังว่าโจทก์ถือกรรมสิทธิ์แทนผู้อื่นนั้น เห็นว่า ข้อขัดแย้งดังกล่าวไม่ใช่ข้อสาระสำคัญคดีนี้ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.3 แนชัดว่าโจทก์มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ได้จดทะเบียนแล้ว ย่อมสันนิษฐานไว้ก่อนว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1373 จำเลยกล่าวอ้างว่าโจทก์มิใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 5537 จำเลยจึงมีหน้าที่นำสืบหักล้างข้อสันนิษฐานดังกล่าว แต่จำเลยมิได้นำสืบหักล้างให้เห็นว่าโฉนดที่ดินตามเอกสารหมาย จ.3 ซึ่งเป็นเอกสารมหาชนนั้นว่าไม่ถูกต้องอย่างไร และจำเลยไม่นำพยานมาสืบให้ฟังได้ว่า โจทก์มีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทนผู้อื่นข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 5537 ตำบลช่องนนทรี อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาต่อไปตามฎีกาของจำเลยข้อ 2 มีว่า ทางพิพาทเป็นการจำยอมหรือไม่ โจทก์นำสืบว่า โจทก์และคนในครอบครัวได้ใช้ทางพิพาทเป็นทางเดินไปยังวัดคลองใหม่ ออกสู่ถนนนางลิ้นจี่และถนนสาธุประดิษฐ์ ตามที่บรรพบุรุษได้เดินสืบต่อกันมาและเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว โดยไม่มีผู้ใดโต้แย้ง ส่วนจำเลยนำสืบว่าไม่มีทางพิพาทอยู่ในที่ดินของจำเลย สะพานไม้ในที่ดินของจำเลยเพิ่งจะมีขึ้นหลังจากจำเลยซื้อที่ดินพิพาทแล้ว พิเคราะห์แล้วเห็นว่า นอกจากตัวโจทก์และคนในครอบครัวโจทก์ได้แก่นายยินดีทิมมาศย์ นายอดิศักดิ์ ทินมาศย์ และร้อยตำรวจเอกอัชรินทร์ทิมมาศย์ เป็นพยานแล้ว โจทก์ยังมีนางจินตนา บุญประเสริฐและนายพุก พรหมหมัด ชาว

บ้านบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นคนในท้องถิ่นที่ตั้งกล่าวมาเบิกความสนับสนุนว่า โจทก์และคนในครอบครัวโจทก์ได้ใช้ทางเดินบนคันสวนในที่ดินของโจทก์และที่ดินของจำเลยตามทางพิพาทไปยังวัดคลองใหม่ และออกสู่ถนนสาธารณะ โดยเฉพาะนางจินตนา เบิกความยืนยันว่า มารดาและน้ำของพยานซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินเดิมแปลงที่เป็นของนางประภา วิริยะประไพกิจในปัจจุบันซึ่งอยู่ตรงต่อจากจุดทางเดินของโจทก์ทางด้านทิศตะวันตกไม่ยินยอมให้โจทก์และคนในครอบครัวโจทก์เดินผ่านที่ดินแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ข้อเท็จจริงยังได้ความจากการเดินเผชิญสืบทอดที่ดินพิพาทของศาลชั้นต้นรวม 2 ครั้งตามรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2532 และฉบับลงวันที่ 28 เมษายน 2532 ว่ามีคันสวนในที่ดินของโจทก์กว้างประมาณ 4 เมตรโดยตลอดริมสวนมีสะพานไม้กระดานขนาดกว้าง 2-3 แผ่น จนมาถึงที่ดินของจำเลยซึ่งสร้างเป็นกำแพง ฝังตรงกันข้ามของถนนพระรามที่ 3 เยื้องกับทางพิพาทเป็นเส้นทางเข้าวัดคลองใหม่ หลังวัดคลองใหม่ทางทิศตะวันตกมีคันสวนกว้าง 4.30 เมตรไปสู่ถนนสาธุประดิษฐ์และถนนนางลิ้นจี่ ริมคันสวนทั้งสองข้างมีต้นมะพร้าวและต้นหมากปลูกอยู่ตลอดคันสวน จึงมีเหตุให้น่าเชื่อว่าต้องมีคันสวนผ่านที่ดินของจำเลยก่อนที่ถนนพระรามที่ 3 จะตัดผ่านเชื่อมกับทางข้างวัดคลองใหม่และน่าเชื่อว่าโจทก์และคนในครอบครัวโจทก์เมื่อจะเข้าออกได้ใช้คันสวนดังกล่าวไปสู่วัดคลองใหม่ถนนสาธุประดิษฐ์และถนนนางลิ้นจี่มาตั้งแต่ที่ดินทั้งสองแปลงยังเป็นที่ดินแปลงเดียวกัน ส่วนจำเลยคงนำสืบแต่เพียงว่าก่อนซื้อที่ดินเจ้าของที่ดินเดิมได้รับรองว่าไม่มีการจำยอมใด ๆ หรือการรอนสิทธิในที่ดินดังกล่าวโดยมีหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทเอกสารหมายเลข 3 ระบุข้อความดังกล่าวไว้และมีนางพงา วรรณะกุลกรรมการบริษัทจำเลย นายอรรถสิทธิ์ คุณูปถัมภ์ นายวิระชัยวงศ์พานิช และนายกิตติ เจนเนติศิลป์ เป็นพยานเบิกความว่าได้ไปตรวจดูที่ดินพิพาทแล้วไม่ปรากฏว่ามีทางเดินพิพาทหรือสะพานไม้ก่อนซื้อเพียงจะมาพบสะพานไม้ในภายหลัง แต่จำเลยมิได้นำเจ้าของที่ดินเดิมคนก่อน ๆ หรือคนในท้องถิ่นที่ตั้งกล่าวมาสืบสนับสนุนให้มีน้ำหนักรับฟังตาม

ข้ออ้างของจำเลยดังกล่าวพยานหลักฐานของโจทก์จึงมีน้ำหนักน่าเชื่อถือกว่าพยานหลักฐานของจำเลยข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โจทก์และคนในครอบครัวโจทก์ได้ใช้ทางพิพาทเป็นเส้นทางไปวัดคลองใหม่และออกสู่ทางสาธารณะมากกว่า 10 ปีแล้ว มีปัญหาต่อไปว่า ทางพิพาทดังกล่าวตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์หรือไม่ เห็นว่า ก่อนปี 2498 ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 5484 ตามเอกสารหมาย จ.2 ล้วนแต่อยู่ในตระกูลของโจทก์ทั้งสิ้น การใช้ทางพิพาทในระยะดังกล่าวจึงเป็นการเดินโดยขออาศัยกันระหว่างหมู่ญาติหรือเป็นการเดินโดยถือวิสาสะจึงไม่อาจได้ภาระจำยอมแต่อย่างใด แต่นับตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2498 ที่นายสำฤทธิ์ ทิมมาศย์ ชายที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกไป และมีการโอนกันต่อ ๆ มาจนถึงจำเลยซึ่งรับโอนเมื่อปี 2526 เป็นเวลาเกินกว่า 10 ปี การใช้ทางพิพาทของโจทก์และคนในครอบครัวเป็นไปโดยสงบ และเปิดเผย มิได้ขออนุญาตจากผู้ใด ทางพิพาทจึงตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์โดยอายุความฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

ปัญหาต่อไปตามฎีกาของโจทก์ข้อ 3 มีว่า ทางพิพาทเป็นทางจำเป็นหรือไม่ ได้ความจากคำฟ้องและคำเบิกความของโจทก์ว่าที่ดินของโจทก์ทางด้านทิศตะวันออกติดลำแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าบ้านโจทก์มีทำน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ เห็นว่า แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นทางสาธารณะที่โจทก์สามารถใช้สัญจรไปมาได้อยู่แล้ว แม้ในปัจจุบันจะไม่ค่อยมีผู้ใช้สัญจรไปมาก็ยังถือไม่ได้ว่าที่ดินของโจทก์ถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะได้ทางพิพาทในที่ดินของจำเลยจึงไม่เป็นทางจำเป็น ฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาต่อไปตามฎีกาโจทก์ข้อแรกมีว่า โจทก์ฟ้องขอให้เปิดทางภาระจำยอมกว้าง 3.50 เมตร จำเลยมิได้ให้การต่อสู้เกี่ยวกับความกว้างของทางภาระจำยอม แต่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่าทางภาระจำยอมกว้าง 1 เมตร เป็นการวินิจฉัยนอกฟ้องนอกประเด็นหรือไม่ เห็นว่า จำเลยให้การต่อสู้ว่า โจทก์และคนในครอบครัวโจทก์ไม่เคย

ใช้คันสวนบนที่ดินของจำเลยเป็นทางผ่านออกสู่ทางสาธารณะจึงไม่มีทางภาระจำยอม
คำให้การของจำเลยย่อมมีความหมายไปถึงว่าไม่มีทางภาระจำยอมแม้แต่เมตรเดียว
ไปด้วย ดังนั้น การที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยไปถึงความกว้างของทางภาระจำยอมว่ามี
ขนาดไหนจึงอยู่ในขอบเขตของคำให้การของจำเลยแล้ว ไม่ใช่เป็นเรื่องนอกฟ้องนอก
ประเด็นแต่อย่างใด ฎีกาโจทก์ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาต่อไปตามฎีกาโจทก์ข้อ 2 มีว่า ทางภาระจำยอมมีความกว้างขนาดไหนใน
ปัญหานี้ได้ความจากโจทก์และคนในครอบครัวโจทก์ว่าแนวคันสวนในที่ดินของโจทก์
และจำเลยมีความกว้างประมาณ 3.50 เมตร ถึง 4 เมตร ริมคันสวนทั้งสองข้างปลูก
ต้นไม้จำพวกมะพร้าว หนาแน่น ชมพุ่ม เว้นว่างตรงกลางสำหรับเป็นทางเดินและได้ความ
จากภาพถ่ายหมายเลข 5 ภาพที่ 7 และภาพที่ 8 ซึ่งเป็นภาพสะพานไม้ที่โจทก์ทำขึ้น
เป็นทางเดินบนคันสวนพิพาทมีความกว้างเพียงไม้กระดาน 2 ถึง 3 แผ่น เห็นว่า
ส่วนที่ใช้เป็นทางเดินที่แท้จริงควรมีความกว้างไม่ถึง 1 เมตร หากใช้ 3.50 เมตรดังที่
โจทก์ฎีกาไม่ ที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดให้ทางภาระจำยอมกว้าง 1 เมตร นั้น เหมาะสม
แก่รูปการณ์แล้ว ฎีกาโจทก์ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาต่อไปตามฎีกาของจำเลยข้อ 3 มีว่า ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ย้ายภาระ
จำยอมไปสู่สุดแนวเขตที่ดินของจำเลยทางด้านทิศใต้เป็นการวินิจฉัยนอกฟ้องนอก
ประเด็นหรือไม่นั้น โดยที่ทางพิพาทอยู่ห่างจากแนวเขตที่ดินของจำเลยทางด้านทิศ
ใต้เข้ามา 2.30 เมตรการใช้ทางพิพาทของโจทก์ย่อมไม่สะดวก อีกทั้งการสร้างรั้ว
หรืออาคารในที่ดินของจำเลยโดยเว้นทางพิพาทไว้ ย่อมทำให้จำเลยเสียที่ดินด้านสุด
แนวเขตที่ดินทางด้านทิศใต้ เว้นแต่จะกั้นรั้วหรือสร้างอาคารเป็นสองตอนซึ่งเป็นการ
เพิ่มภาระแก่จำเลยและใช้ประโยชน์จากที่ดินทางด้านทิศใต้แนวเขตที่ดินดังกล่าวไม่
ได้เท่าที่ควรแต่หากได้ย้ายทางพิพาทจากที่เดิมไปอยู่ตรงสุดแนวเขตที่ดินของจำเลย
ทางด้านทิศใต้แล้วย่อมไม่ทำให้ความสะดวกในการใช้ทางเดินของโจทก์ต้องลดน้อย

ลงกลับจะทำให้โจทก์เดินระยะทางสั้นเข้าเพราะไม่ต้องเดินวกไปทางขวามากดังที่เป็นอยู่เดิม และในขณะเดียวกันจำเลยก็สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการย้ายภาระจำยอมดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่จำเลยดังกล่าวมาข้างต้นด้วย ตามนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1392 และปรากฏตามคำร้องของจำเลยฉบับลงวันที่ 28 เมษายน 2532 ที่ขอให้ยกเลิกคำสั่งหรือหมายห้ามชั่วคราวจำเลยที่จำเลยยื่นต่อศาลว่า จำเลยได้ขอย้ายภาระจำยอมไปทางด้านทิศใต้สุดแนวเขตที่ดินของจำเลยแล้วดังปรากฏตามแผนที่สังเขปท้ายคำร้องฉบับดังกล่าว ดังนั้น การที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ย้ายภาระจำยอมไปสุดแนวเขตที่ดินของจำเลยทางด้านทิศใต้จึงไม่เป็นการนอกฟ้องนอกประเด็นแต่อย่างใด คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ในข้อนี้จึงไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังขึ้น

ปัญหาต่อไปตามฎีกาโจทก์ข้อ 4 มีว่า จำเลยต้องไปจดทะเบียนทางภาระจำยอมแก่โจทก์หรือไม่ เห็นว่า การจดทะเบียนภาระจำยอมนั้นฟังต้องถือว่าเป็นการอันจำเป็นเพื่อรักษาและใช้ภาระจำยอมประการหนึ่ง ตามนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1391ซึ่งบัญญัติว่า เจ้าของสามยทรัพย์มีสิทธิทำการทุกอย่างอันจำเป็นเพื่อรักษา และใช้ภาระจำยอม แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง ฯลฯเช่นนั้นแม้จะได้มาซึ่งภาระจำยอมโดยอายุความ โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของสามยทรัพย์ก็ชอบที่จะเรียกให้จำเลยเจ้าของภาระทรัพย์จดทะเบียนทางภาระจำยอมแก่ตนได้ ฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้น

ปัญหาข้อสุดท้ายตามฎีกาโจทก์ข้อ 5 มีว่า มีเหตุอันสมควรที่จะบังคับให้จำเลยทำสภาพที่ดินบนทางพิพาทให้เหมือนเดิมหรือไม่ในปัญหานี้ ได้ความตามทางนำสืบของโจทก์ว่า โจทก์สร้างสะพานไม้ใช้เดินเข้าออกดังปรากฏตามภาพถ่ายหมายเลข จ.5 และ จ.6 เนื่องจากน้ำท่วมคันสวน และได้ความจากคำเบิกความของนายยินดีพยานโจทก์ตอบทนายจำเลยถามค้านว่า เวลานั้นน้ำท่วมบางครั้งต้องเดินลุยน้ำแต่หากท่วม

มากก็ต้องถอนกางเกงแล้วเดินออกไป ในปี 2521 น้ำท่วมถึงเอว ดังนั้นจำเลยถมดินทำให้ทางราชการจ่ายอมสูงกว่าระดับคันสวนในที่ดินของโจทก์ก็ยิ่งทำให้โจทก์และคนในครอบครัวโจทก์ได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น ไม่ต้องเดินสะพานไม้อีกต่อไปการถมดินของจำเลยดังกล่าวมิได้ทำให้ประโยชน์แห่งการจ่ายอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกแต่อย่างใด ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยมานั้นชอบแล้ว"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ที่ดินโฉนดเลขที่ 5484 ตำบลช่องนนทรีอำเภอยานนาวา (พระโขนง) กรุงเทพมหานคร ด้านสุดแนวเขตที่ดินทางด้านทิศใต้กว้าง 1 เมตร ยาวตลอดแนวเขตที่ดินจากด้านทิศตะวันออกไปจนสุดยังด้านทิศตะวันตกตกเป็นการจ่ายอมแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 5537 ตำบลช่องนนทรี อำเภอยานนาวา (พระโขนง) กรุงเทพมหานครของโจทก์ ให้จำเลยรื้อรั้วกำแพงคอนกรีตที่ปิดกั้นเปิดเป็นทางและไปจดทะเบียนทางราชการจ่ายอมแก่โจทก์ หากไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล รางฆาณูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>